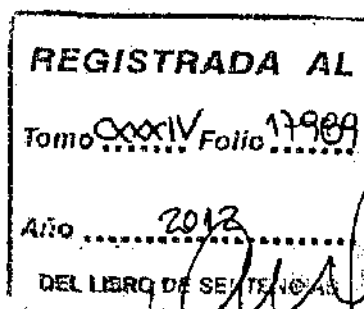


Poder Judicial de la Nación

/// del Plata, 19 de abril de 2012.-



VISTOS:

En estos caratulados "DIRECTV ARGENTINA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE BENITO JUAREZ s/ ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA - MEDIDA CAUTELAR". Expediente N° 13.413 del registro interno de este Tribunal, procedente del Juzgado Federal N° 2 de Azul (Expte 22.950).-

Y CONSIDERANDO:

El Dr. Tazza dijo:

I. Llegan los autos a esta Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por el Dr. Juan Martin Jovanovich en representación de la actora, DIRECTV ARGENTINA S.A. contra la resolución de fs. 51/52 que rechaza la medida de no innovar solicitada, con el objeto de evitar la ejecución por el cobro de la tasa exigida por la Ordenanza General Tributaria de la Municipalidad de Benito Juárez en concepto de pago de publicidad y propaganda en la vía pública.

El memorial de fs. 76/95 presentado por la actora cuestiona lo resuelto por el a quo en cuanto apoya la existente coincidencia del objeto de la cautelar con la cuestión medular del asunto conformando ello un adelanto de jurisdicción. Sostiene que a su vez, tampoco se encuentran acreditados los presupuestos legales previstos en el art. 230 del CPCCN en virtud de una cancelación de deuda realizada por DIRECTV correspondiente a un periodo fiscal no discutido en autos. Por último, aduce que el peligro en la demora queda acreditado con la intimación de pago emitida por la Municipalidad en relación al período 2.010 y la exigencia de precio pago como requisito de admisibilidad para el acceso a la justicia provincial.

Resumidos los agravios, encontrándose esta causa en condiciones de resolver con el llamamiento de autos de fs. 100, procedemos a abocarnos al recurso interpuesto.

II. En el presente caso la medida iniciada se encuentra dirigida a disipar el estado de incertidumbre existente sobre la pretensión de la Municipalidad de cobrar el tributo denominado "Derechos de Publicidad y Propaganda establecido en el art. 117 de la ordenanza Fiscal de la Municipalidad de Benito Juárez". Ante el rechazo de su planteo la recurrente intenta rebatir lo sostenido por el a quo en cuanto sostiene que existe coincidencia entre el objeto de la medida cautelar y el objeto final del litigio, y en cuanto a la falta de cumplimiento de los recaudos que la medida exige.

Respecto de las medidas innovativas contra actos de la administración pública vale recordar la presunción de validez de la que estos gozan. Ahora, en el caso, resta analizar si el otorgamiento de la medida solicitada implicaría adelantar el contenido de la sentencia. Su otorgamiento requiere indefectiblemente la

USO OFICIAL

acreditación de los presupuestos que la normativa exige y la prudencia lógica del tribunal según las particularidades de cada caso.

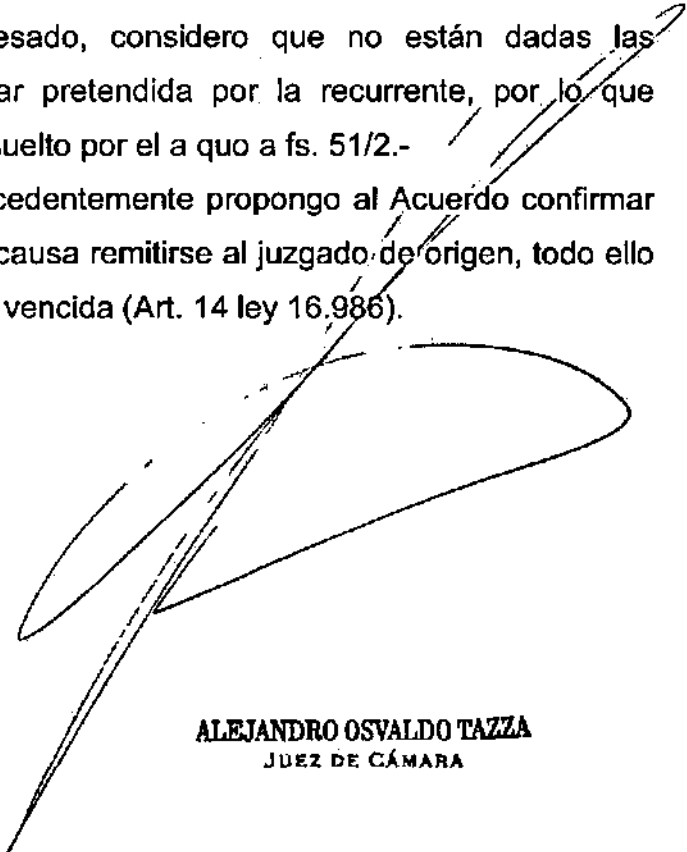
De la compulsa de las actuaciones observamos que el objeto de la cautelar solicitada (ver fs. 32 vta.) es coincidente con el objeto principal del litigio (ver fs. 17) toda vez que el fin primordial de ambos requerimientos es evitar el inicio de una posible ejecución fiscal contra DIRECTV del tributo denominado "Derechos de Publicidad y Propaganda" establecidos en el art. 117 de la Ordenanza Fiscal de la Municipalidad de Benito Juárez. El fin primordial de este tipo de medidas consiste en asegurar el resultado práctico de la sentencia, no adelantar su contenido, lo que importaría prejuzgamiento por parte del sentenciante de grado en el caso que así lo declare.

Ahora aclarado lo que antecede, entendemos que los argumentos brindados por la actora para acreditar la verosimilitud en el derecho de la medida solicitada, estos es, que la Municipalidad de Benito Juárez no presta servicio alguno de habilitación o control respecto de las supuestas publicidades o propagandas de DIRECTV (pto. a, fs. 82); no existe razonable equivalencia o proporción entre la tasa y la importancia del servicio prestado (pto. b, fs. 85 vta.), y por último, que la Municipalidad prestaría un servicio de control, verificación y registro de las publicidades y propagandas de DIRECTV en el desarrollo de su actividad siendo que el control del servicio de radiodifusión es competencia exclusiva del Gobierno Nacional y regulado por normas federales cuya colisión resulta evidente (pto. c, fs. 88) son cuestiones que no habilitan en el presente el acogimiento de la medida siendo que tales aseveraciones podrán ser valoradas por el a quo al momento de dictar sentencia definitiva en autos.

En virtud de todo lo expresado, considero que no están dadas las condiciones para otorgar la cautelar pretendida por la recurrente, por lo que propongo al Acuerdo confirmar lo resuelto por el a quo a fs. 51/2.-

III. Por todo lo expuesto precedentemente propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de fs. 51/52 debiendo la causa remitirse al juzgado de origen, todo ello con costas de Alzada a la recurrente vencida (Art. 14 ley 16.986).

Tal es mi voto.-



ALEJANDRO OSVALDO TAZZA
JUEZ DE CÁMARA

El Dr. Ferro dijo:

Que examinado el voto del Sr. Juez que me precede en la votación y las constancias de orden fáctico y jurídico que informan a los presentes obrados, he de adherir a la solución propuesta y añadir una breve argumentación al respecto.

Entrando a analizar la pretensión recursiva y respecto de algunas expresiones vertidas por la demandada cabe señalar que, en cuanto a su legitimación para el cobro de tasas, nadie lo discute en esta instancia, solo se cuestiona la aplicación de un importe correspondiente al pago de un derecho de publicidad y propaganda dentro de la jurisdicción del Municipio demandado, lo que será decidido en la oportunidad procesal pertinente.

En el caso de marras, se trata de confirmar o no la cautelar dictada por el Sr. Juez a-quo y, como dije, adelanto desde ya que la postura de la firma actora no puede prosperar.

Conviene remarcar en lo que concierne a las medidas cautelares, que para su procedencia es necesario un análisis previo acerca de la existencia o no de un derecho garantizado por la ley y la justificación del peligro en la demora. Si bien aquel no debe interpretarse con criterio restrictivo, ni exige un examen de certeza, indiscutiblemente, deben existir en la causa elementos de juicio idóneos para formar la convicción acerca de la bondad de los mismos y pesa sobre quien la solicita, acreditar prima facie la existencia de tales condiciones exigidas por la ley procesal (art. 377 del CPCC) ("A. Barilari SRL c/ A. Barilari SA s/ cesación de nombre y medida cautelar - s/ incidente art. 250 CPCC", exped. N°. 6977/03; "Villagra, Liliana E. c/ Estado Nacional y otros s/ amparo - expedientillo apelación medida cautelar"; exped. N° 8337/05 "APU c/ Universidad Nacional de Mar del Plata y otro s/ amparo", expte. N° 7072/03 "AAVISA c/ American Airlines y otros s/ juicio sumarísimo", expte. N° 4973/00.

A ese fin, es preciso indagar sobre el cumplimiento de la exigencia procesal atinente a los presupuestos que las medidas cautelares deben ostentar para pensar en su viabilidad; tal la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la prestación de una contracautela.

Debo hacer mención, también, y como lo he dicho en autos "Mendez, Fernando c/ D.G.I. s/ Amparo"¹ y "Cam. Arg. Buques Pesquero. de Altura c/ Consejo Federal Pesquero; SAGPyA; Subsec. de Pesca s/ amparo"², que si bien la declaración de medidas cautelares dictadas contra la administración pública, en este caso neutralizar los efectos de un Decreto Municipal -por vía de principio- deben atenerse a un criterio restrictivo frente a la presunción de legitimidad de la que gozan sus actos; sin embargo tal doctrina no reúne carácter de absoluto, toda

¹ T.XV. F.3155

² T.XXIV. F.4869/99

vez que debe ceder cuando se impugnan los actos sobre una base prima facie verosímil y se acredita la arbitrariedad de los mismos (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702), tal el caso de autos conforme lo dicho ut supra.

Y en ese contexto, la decisión del Municipio de Benito Juárez, en virtud de la cual se obligó a abonar a la empresa actora un importe referido a derechos de publicidad y propaganda, conforme los arts. 20, 23 y 26 de la OF. de ese Municipio, unido a las facultades que disponen conforme la Ley Orgánica de las Municipalidades, permite inferir prima facie y con el grado de provisoriedad con que se dictan las medidas cautelares, que dicha Intendencia posea derecho a tal proceder ejecutivo; pero además existe otra circunstancia que, por el momento, justificaría el accionar del municipio y es que la actora abonó sin reserva alguno los montos reclamados como dan cuenta las constancias administrativas, tal como bien lo dice el Sr. Juez de la instancia anterior.

Frente a dichas normativas, que parecieran dar razón a la demandada como titular del derecho al cobro de la publicidad y propaganda, se halla la actora que cuenta, por ahora, solo con sus manifestaciones y la invocación de derechos que dicen le dan razón para tal cuestionamiento; sin embargo y en base a la provisoriedad de las cautelares y la etapa que desandamos, no debemos obviar que tal actuación municipal comporta un status jurídico hacia el actor que le otorgaría una protección normativa, conforme el régimen aplicable, para el cobro de tales conceptos.

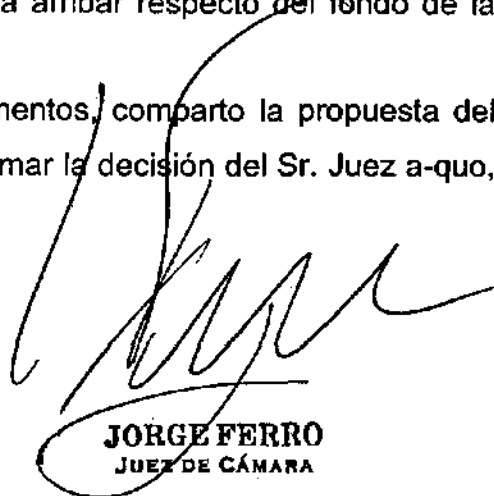
Tal presunción de legitimidad determina, entonces y por el momento, la improcedencia de las medidas cautelares contra los actos de los poderes públicos, salvo, claro está, que ostenten una irrazonable determinación lo que conlleva a una pérdida de aquella presunción y sean admitidas (fallos 313:521, 819, entre otros), extremo que no observa por el momento.

En la especie, a mi juicio, al confirmar la decisión del Sr. Juez de la 1ª Instancia y desestimar la medida cautelar pretendida implicaría - por el momento - convalidar las atribuciones del Poder Municipal conforme un fundamento razonable o jurídico suficiente.

Resta por último aclarar, que el presente pronunciamiento no implica abrir ningún juicio respecto de la solución que se ha arribar respecto del fondo de la cuestión.

Por lo expuesto, añadiendo estos argumentos, comparto la propuesta del Sr. Juez preopinante y propongo también confirmar la decisión del Sr. Juez a-quo, materia de esta apelación.

Tal es mi voto.



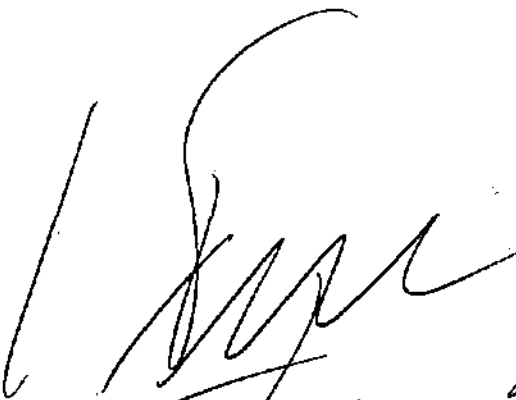
JORGE FERRO
JUEZ DE CÁMARA

Por todo lo expuesto, este Tribunal

RESUELVE:

Confirmar la sentencia de fs. 51/52, debiendo la causa remitirse al juzgado de origen, todo ello con costas de Alzada a la recurrente vencida (Art. 14 ley 16.986).

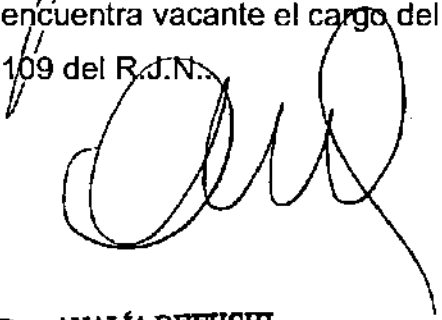
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVA.


JORGE FERRO
JUEZ DE CÁMARA


ALEJANDRO OSVALDO TAZZA
JUEZ DE CÁMARA

USO OFICIAL

Se deja constancia que se encuentra vacante el cargo del tercer integrante de este Tribunal a los fines del art. 109 del R.J.N.


Dra. ANALÍA DEFUCHI
SECRETARIA
DE LA CÁMARA FEDERAL
DE APELACIONES DE MAR DEL PLATA